

1500554-32.2021.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Zander Barbosa Dalcin

Comarca: Maracaí

Foro: Foro de Maracaí

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... no fundo do quintal. Ele confirmou o tráfico, disse que fazia disk-entrega. Alguns pedidos eram feitos pelo aparelho de telefone celular. Ele disse que os entorpecentes encontrados com ele seriam para o uso, já os entorpecentes encontrados no interior da residência, disse que era para o tráfico. As porções estavam tanto separadas em porções individuais como à granel. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Maracaí

Foro de Maracaí

Vara Única

Av. São Paulo, 440, Maracai-SP - cep 19840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500554-32.2021.8.26.0580 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500554-32.2021.8.26.0580

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2354823/2021 - DEL.POL.MARACAI, 22212819 - DEL.POL.MARACAI, 561/21/112 - DEL.POL.MARACAI, 2354823 - DEL.POL.MARACAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO FAUSTINO DE BRITO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Zander Barbosa Dalcin

Vistos.

Gustavo Faustino de Brito foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, trazia consigo e tinha em depósito, sem autorização legal, para posterior entrega ao consumo de terceiros, as substâncias entorpecentes descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 19/20 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 132/135, sendo certo que estas causam dependência física e psíquica.

O denunciado foi notificado (fl. 238) e apresentou defesa preliminar (fls. 197/198).

A denúncia foi recebida em 21/03/2022 (fls. 204/206).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa e interrogado o acusado (fls. 263/265 e 338/339).

Encerrada a instrução o Ministério Público, em Memoriais, requereu a condenação, nos exatos termos da denúncia (fls. 345/349).

A defesa, em Memoriais, requereu, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da prova, ante a invasão de domicílio. No mérito, defendeu a ausência de provas para a condenação e requereu a desclassificação para a figura típica prevista no artigo 28, da Lei de Drogas (fls. 355/363).

Relatei. Decido.

PRELIMINAR

Nulidade da prova - Invasão de domicílio

No que concerne à entrada policial na residência do réu, oportuno lembrar, que, nas hipóteses de flagrante em crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, cuja consumação se protraí no tempo, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, conforme Tema 280, do Supremo Tribunal Federal:

"Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio. Art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos ? flagrante delito, desastre ou para prestar socorro ? a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11,2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso". (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-

05-2016)

Além disso, inviável pretender que relato do acusado Gustavo e das testemunhas Stefani e Nadya (inclusive quanto a estas últimas, em face das contradições, abaixo aventadas, restou consolidada a ausência de credibilidade em seus relatos), se sobreponha ao documento de fl. 49, em que se observa que o acusado (Gustavo) franqueou a entrada dos policiais em sua residência, não havendo, portanto, que se cogitar em nulidade (tese defensiva - fls. 356/360).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, laudo de constatação provisória (fls. 28/31), pelo laudo do exame químico-toxicológico definitivo da natureza das drogas (fls. 132/135), documentos de fls. 136/152, laudos periciais de fls. 174/176, 283/293 bem como pela prova oral, coligida sob o crivo do contraditório. A autoria pelo conjunto probatório.

Gustavo Faustino de Brito, réu, perante a autoridade policial (fl. 07), permaneceu em silêncio. Em juízo, afirmou que, na data dos fatos, iria com a sua ex-companheira para a cidade de Assis/SP, para comprar um celular novo. Na altura do primeiro retorno, o carro começou a sair fumaça, fez o retorno e voltou. Parou o carro e estava consumindo um cigarro de maconha com a namorada, sendo que, dentro do carro, tinha mais uma porção de maconha. Solicitou o "socorro". Quando a namorada ia comprar um celular no "muambeiro" por R\$ 250,00, visualizou um carro todo preto na via. Pensou ser o "socorro", mas era o Dr. Rodrigo e o Jorge. Foi abordado pelos policiais, que não gostam dele. Averiguaram o carro, encontraram a porção de maconha e perguntaram se havia mais droga, respondeu que só tinha maconha que estavam fumando. Algemaram o réu e revistaram a namorada, sem autorização, em abuso de autoridade, pois não havia policial mulher. Pegaram R\$ 250,00 dentro do bolso. Foi algemado e colocado dentro da viatura e levado para a sua residência. Adentraram à residência sem autorização. Informou ao policial que, dentro do carro, cultivava um 'pé de maconha' para tratamento, em razão de uma cirurgia. Tinha o pé de maconha de 1,80m, macho, para fazer remédio e se tratar. Tem setenta e cinco sequelas pelo corpo. Negou ter outras drogas na residência. A maconha é usada para se tratar da cirurgia que fez no pescoço, sofreu acidente, permaneceu na UTI. É pai de duas crianças. Os policiais não gostavam do depoente porque andava de moto para baixo e para cima, era rolista, revendia as motos. Com o dinheiro que recebia, pagava a ex-mulher e construía a própria casa. A esposa foi liberada. Negou ter trazido problemas para a polícia. Era entregador do mercado Roma. Diz que apenas reconheceu as drogas posteriormente. Só tinha a porção do carro e o pé de maconha. . Apontou como sua a linha telefônica (18 99614-1415). O celular da Xiaomi não é do depoente. Nega que o seu aparelho celular foi apreendido pelos policiais.

Jorge Henrique Barauna, testemunha de acusação, policial militar, tanto em sede inquisitorial (fl. 05), como em Juízo, disse que receberam denúncias anônimas, através do 181, que apontavam que o acusado estava praticando tráfico de drogas na residência dele, rua Carlos Matis, 109. Na data dos fatos, realizaram patrulhamento e visualizaram Gustavo em frente à residência dele. Fizeram a abordagem, encontraram duas porções de entorpecentes. Na ocasião, ele disse que seria para uso próprio. Questionado se existia mais entorpecentes na casa, ele confirmou a existência, autorizou a entrada e indicou o local. Encontraram maconha, crack e cocaína. Ele entregou quantia em dinheiro e mostrou pé de maconha que estava sendo cultivado no fundo do quintal. Ele confirmou o tráfico, disse que fazia disk-entrega. Alguns pedidos eram feitos pelo aparelho de telefone celular. Ele disse que os entorpecentes encontrados com ele seriam para o uso, já os entorpecentes encontrados no interior da residência, disse que era para o tráfico. As porções

estavam tanto separadas em porções individuais como à granel. Conhecia o acusado de algumas abordagens e das denúncias que apontavam tanto o nome do acusado como o apelido. Foi encontrado na frente da residência dele. Não estava com a companheira dele. Gustavo estava com duas porções de maconha, que disse que era para uso pessoal. Antes da abordagem, não visualizou Gustavo entregando algo pra alguém. Desconhece que estava em carro, sabe que ele tem uma moto de grande porte.

Rodrigo Cintra Nunes, testemunha de acusação, policial militar, durante a instrução, apresentou depoimento semelhante ao depoimento prestado perante a autoridade policial (fl. 05), afirmou que estavam em patrulhamento no dia dos fatos, e, como já tinham recebido quatro denúncias anônimas sobre o acusado, realizaram abordagem, próximo à residência dele. Em revista pessoal, encontraram duas porções de maconha. Tinha recebido informações de que o réu atuava por meio de entrega de entorpecentes via delivery. Encontraram duas porções de maconha, embaladas para comércio. Questionado, o réu confessou a venda de drogas via delivery, permitiu a entrada dos policiais na residência e indicou o local em que guardava as drogas. Encontraram maconha, crack, aparato (petrechos) para embalar a droga em porções individuais e a quantia de R\$ 250,00. Ainda, o réu indicou, no fundo da residência dele, o local em que cultivava uma "planta de maconha". Primeiramente, Gustavo foi abordado próximo à rodovia SP-270. Depois, fizeram contato com ele, ele autorizou a entrada no domicílio dele, e, inclusive, assinou papel de autorização e indicou onde estava escondido os entorpecentes. Ele foi conduzido na viatura. Stefani não foi conduzida, ficou na rodovia. No local, tinha um indivíduo que Gustavo ia passar droga. Porém, quando viu a presença dos policiais, evadiu-se do local.

Carlos Eduardo Pincerati, testemunha de acusação, policial civil, em juízo, apresentou depoimento em consonância com o apurado durante inquérito policial (fl. 138), declarou que o réu era bem conhecido dos meios policiais (civil e militar) pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas. Receberam várias denúncias de que, em todas as residências que ele se fixava, eram usadas como ponto de venda de drogas. Inclusive, realizaram buscas nas residências, mas não lograram êxito em encontrar drogas. No ano passado, em outubro, salvo engano, Gustavo se mudou para a Rua Carlos Mathis, bairro Jardim Morumbi. A partir do momento em que mudou para o local, as denúncias anônimas começaram a aparecer indicando que ele estava comercializando drogas na residência dele. Fizeram campanhas em horários diversos e, verificaram, que, de fato, tinha um grande movimento no local, dando conta que ele estava realizando tráfico de drogas no local. Chegou a ser confeccionado um relatório com a indicação para a realização de busca e apreensão domiciliar no local. Nesse ínterim, salvo engano, no dia 30/12, a polícia militar intensificou o patrulhamento na região e identificaram Gustavo em atitude suspeita, em frente à residência dele. Realizaram abordagem, encontraram duas porções de maconha, embaladas para venda. Indagaram Gustavo, que acabou admitindo que tinha mais drogas na residência, inclusive assinou autorização, franqueando a entrada dos agentes em sua residência. Confessou a mercancia de drogas, disse que estava desempregado e que fazia disk-entrega. Na casa dele, os policiais adentraram na residência e encontraram porções de cocaína, crack, maconha e um pé de maconha, além de apetrechos (balança de precisão e embalagens para individualizar porções de drogas), duas tampas de caneta impregnadas de cocaína (utilizava para fazer medição de porções) e R\$ 250,00, em dinheiro. Diante das circunstâncias, foi preso em flagrante. O celular dele foi apreendido, com autorização judicial, foram extraídos dados do aparelho celular apreendido em seu poder, oportunidade em que localizadas várias conversas envolvendo o comércio ilícito de entorpecentes. Não estava presente no dia da apreensão de Gustavo. Não filmaram atuação de Gustavo, só visualizaram. O depoente não chegou a abordar algum adquirente de drogas. Nas duas buscas que realizou, não localizou entorpecentes na casa dele. Não presenciou a confissão de Gustavo aos policiais militares. Gustavo, na época da autuação dele, permaneceu em silêncio. A abordagem foi realizada em frente à residência dele. Não tem conhecimento se foi abordado na rodovia.

Stefani Fernandes da Silva, testemunha de defesa, declarou que foram abordados na rotatória, próximo ao cemitério. Iriam até Assis para comprar um celular. Na oportunidade, estavam usando maconha, não tinha mais nada no carro. Foram abordados por três ou quatro policiais. Não tinha cocaína ou crack. Após a abordagem, foram levados até a casa do acusado. Ninguém autorizou a entrada. Ele saiu da casa com um pé de maconha. Não saiu com mais nada. Somente Gustavo foi preso. Gustavo tem filhos, é o provedor da família.

Nadya Ferreira Gomes, testemunha de defesa, afirmou que, quando chegou, Gustavo estava no interior da residência dele. Entrou no local porque a mãe dele estava apavorada. Os policiais estavam perguntando se tinha mais drogas, Gustavo respondia que não. Só tinha um pé de maconha. Encontraram a droga com ele no carro. Foram ao trevo, próximo ao cemitério, mas o carro estava sozinho. Gustavo não autorizou a entrada na casa, pegaram a chave e foram entrando. Gustavo estava trabalhando como servente e ajudante de pintor. Tem 02 filhos, é responsável pelo sustento deles. Só viu os policiais saindo com o pé de maconha.

Expletivo consignar, de saída, a discrepância entre o relato do réu (Gustavo) e da testemunha Stefani no que se refere à abordagem policial que culminou na prisão de Gustavo. O primeiro (Gustavo) aventou que a abordagem ocorreu pelos policiais Rodrigo e Jorge, ao passo que a segunda (Stefani), salientou que a abordagem ocorreu por três ou quatro policiais.

Outro ponto a merecer destaque reside na evidente contradição dos relatos de Stefani e Nadya quanto a negativa de Gustavo em permitir a entrada policial em sua residência. No aspecto, observa-se que preditos relatos são refutados pelo documento de fl. 49 (autorização de entrada policial na residência do réu Gustavo), a demonstrar que, ao contrário do alegado pelas referidas testemunhas, a inserção policial na residência do acusado (Gustavo) contou com a aquiescência deste.

Evidencia-se, portanto, que as considerações expendidas por referidas testemunhas (Stefani e Nadya), ante as contradições, alhures apontadas, restam prejudicadas, mormente a evidente ausência de credibilidade em seus relatos.

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação é medida de rigor.

O tipo descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06 é misto alternativo, de natureza múltipla ou de conteúdo variado, ou seja, todas as condutas nele descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal. Em outras palavras, o crime se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de comercialização da droga.

O que demonstra a prática do tráfico ilícito de drogas é o dolo do agente de transferir ou repassar a droga a usuários, nos termos de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos presentes no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Eis o que estabelece o artigo 33 da Lei de Antidrogas:

"Art. 33 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

No caso dos autos, a forma de acondicionamento da droga e as denúncias existentes (fls. 136/152) permitem concluir que predita droga não se destinava ao uso próprio,

restando bem evidenciado o tráfico, não havendo que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.

Oportuno lembrar, ainda, no que concerne ao depoimento prestado pelos policiais que "a presunção é sempre a favor da autoridade judiciária ou policial. O que se presume é, realmente, a imparcialidade, a correção, a lealdade, a lisura. Precisamente a exceção é que exige prova. Quem acusa a autoridade de arbitrária, de capaz de coagir para extorquir confissões contra a verdade, de forjar depoimentos, de compelir a assinar o que o réu não disse, está no dever de oferecer provas, pois a acusação é das mais graves, é das mais repugnantes." (Ac. TJ do DF - Ap. crim. 5.371, Rel. Des. José Duarte - Plácido Sá Carvalh.o, CPP, p. 182).

Dessa forma, os testemunhos dos policiais devem prevalecer frente às demais testemunhas (Stefani e Nadya, cuja credibilidade dos relatos restou maculada, consoante acima exposto). Além disso, os depoimentos dos policiais foram corroborados pelas informações colhidas do aparelho celular do acusado, que retratam a comunicação empreendida entre Gustavo e usuários de drogas, seus clientes, comprovando que realizava a traficância através de disk-entrega (fls. 136/152 {Relatório Policial e formulários "Disque-Denúncia"} e 284/293 {Laudo Pericial em telefone celular, com diálogos alusivos à traficância e fotos correlatadas à mesma}).

Não se descure, por fim, no aspecto, que, no processo penal, incumbe à parte que alega o fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito o ônus probatório, cabendo, portanto, à defesa, demonstrar a ocorrência efetiva de causas excludentes do crime ou de pressuposto para a imposição de pena, sendo que, na hipótese, predito ônus probandi - pela defesa - não foi satisfeito (CPP, art. 156).

Mutatis mutandis, confira-se:

"SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C.C O ART. 40, INC. III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). APELO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, INFIRMANDO-SE A VERSÃO EXCULPATÓRIA DO ACUSADO - LOCAL PONTO DE VENDA DE DROGAS - QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, BEM COMO CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO, POLICIAIS QUE PRESENCIARAM O RECORRENTE EM ATITUDE TÍPICA DE VENDA DE ENTORPECENTES, NÃO SE COADUNAM COM USUÁRIO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELACIONADA AO LOCAL DO CRIME - DESCABIMENTO - CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE CAMPO DE FUTEBOL - CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PARA TRAFICANTE OCASIONAL - INADMISSIBILIDADE - QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO FATORES QUE NÃO SE COADUNAM COM AQUELE QUE PRÁTICA O CRIME PELA PRIMEIRA VEZ - RÉU PRESO, APÓS SER SOLTO POR ESTE PROCESSO, POR TRÁFICO. PENAS E REGIME BEM DOSADOS - RECURSO DESPROVIDO" (TJSP; Apelação Criminal 0090612-04.2018.8.26.0050; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/11/2021; Data de Registro: 09/11/2021)

Passo à dosimetria da pena.

Observando o gizado no artigo 59 do Código Penal, bem como o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal. O acusado possui antecedentes criminais, conforme certificado à fl. 329 referente aos autos nº. 0001605-06.2015.8.26.0341. Não há elementos, nos autos, que permitam aferir sua conduta social de forma negativa, bem como sua personalidade. Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências foram normais. As drogas apreendidas possuíam natureza diversa

(maconha, cocaína e crack) e o crack e a cocaína apresentam alto poder viciante e destrutivo, a ensejar o aumento da pena-base. Nesse sentido, fixo a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 625 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência específica, conforme certificado às fls. 327/328, referente aos autos sob nº 0000723-10.2016.8.26.0341. Dessa forma, aumento a reprimenda na fração de 1/6, perfazendo o total de 08 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 729 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas.

Na derradeira fase da dosimetria, ausentes causas de diminuição e de aumento da pena, fixo-a, definitivamente, em 08 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 729 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR Gustavo Faustino de Brito como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 729 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas.

Ante o montante da pena aplicada, a presença de maus antecedentes e a reincidência específica, o réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado (cf. artigo 59, III, c.c.artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal).

Ante a quantidade da pena, a presença de maus antecedentes e a reincidência, incabível a substituição da pena por restritiva de direitos (artigo 44, incisos I, II e III do Código Penal) bem como a concessão de sursis (artigo 77, caput, I e II do Código Penal). Além da gravidade concreta da conduta demonstrar que não seria socialmente recomendável.

Deve permanecer sua custódia cautelar, pois não modificadas as situações que demandaram suas necessidades (CPP, art. 387, § 1.º). Trata-se de crime de exacerbada gravidade, que fomenta a criminalidade e discórdia familiar nas grandes e pequenas cidades e coloca em constante desassossego a sociedade e a segurança dos cidadãos de bem. Dessa forma, a decretação da custódia cautelar permanece necessária como medida que se impõe para assegurar a ordem pública.

Ademais, no aspecto, como bem asseverado pelo Ministro Jorge Mussi, no julgamento do Habeas Corpus 68.455/DF não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva, como ocorre in casu.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]

2. No caso, constatado que o paciente respondeu preso a todo o processo, a

exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora, se os elementos apontados no decreto construtivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo.

3. Constatado que o pedido de alteração do regime prisional não foi analisado pelo Tribunal a quo no julgamento do writ originário, fica esta Corte impedida de examinar a questão, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância. Ademais, o tema deve ser apreciado no recurso de apelação já interposto.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 279.487/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014)

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome do condenado no rol de culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

Maracai, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA